À EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE ROSA WEBER, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF

ASSOCIAÇÃO DAS OPERADORAS DE CELULARES – **ACEL,** pessoa jurídica de direito privado, constituída por tempo indeterminado e sem fins econômicos, CNPJ nº 03.059.449/0001-13, com sede e foro em Brasília/DF, na SEPS/EQ 702/902, conjunto B, bloco B (Edifício General Alencastro), 4º andar, CEP 70390-025, com endereço eletrônico gestaoprocessual@ayresbritto.com.br – vem, por seus advogados, perante Vossa Excelência, pelo art. 102, § 1º da Constituição[1], e pelos artigos 1º e 2º, I da Lei nº 9.882/99[2], propor **ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR** contra o conjunto de atos normativos emanados de estados distintos da Federação (Decreto nº 16.073/2022, do Mato Grosso do Sul; e Decreto nº 21.796/2022, da Bahia), elevando o ICMS a alíquotas superiores ao padrão vigente para os demais bens e serviços **sem observância da anterioridade nonagesimal**, em infração ao preceito fundamental constitucional previsto no **artigo 150, III, "c"** (*Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,* ***é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios*** *cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b*).

Seguem: (i) Atos Constitutivos; (ii) cópia de procuração *ad judicia*; (iii) Decreto Estadual nº 16.073/2022, do Mato Grosso do Sul; (iv) Decreto Estadual nº 21.796/2022, da Bahia; (v) cartão CNPJ da Proponente; e (vi) guia e comprovante de pagamento de custas.[3] Solicita-se que as comunicações processuais sejam dirigidas ao advogado Marcelo Montalvão Machado – brasileiro, casado, inscrito nas OABs PA (31.755), DF (34.391), SP (357.553), e SE (4.187) –, integrante de **Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advocacia**, neste endereço: SHIS, QL 22, Conj. 4, Casa 17, CEP nº 71650-245, Lago Sul, Brasília/DF.

---

[1] Art. 102, § 1º A ADPF, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo STF, na forma da lei.
[2] "Art. 1º A argüição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público. Art. 2º Podem propor ADPF: I - os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade;".
[3] "Todos estes têm, desde já, sua autenticidade declarada, nos termos do art. 425, VI do CPC."

1. Da Legitimidade Ativa Reconhecida pelo STF: ACEL[4]

1.1. Este STF erigiu uma rica jurisprudência dedicada ao tema "tributação nas telecomunicações". No RE nº 912.888 (Rel. Min, Teori Zavascki, DJe 10/05/2017), eis a tese do Tema nº 827: *o ICMS incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviços de telefonia, independentemente da franquia de minutos concedida ou não ao usuário*. No RE nº 1.003.758 (red. p/acórdão min. Alexandre de Moraes, DJe 28/05/2021), a tese do Tema nº 705 contou com a seguinte redação: *"A inadimplência do usuário não afasta a incidência ou a exigibilidade do ICMS sobre serviços de telecomunicações"*. Já no RE nº 714.139 (Tema 745), eis a tese: *"Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços"*.

1.2. Nos *leading cases* acima, especialmente no último, cujas razões de decidir são fundamentais para o deslinde da presente controvérsia, o setor de telecomunicações foi ouvido. Estava presente o Sinditelebrasil, entidade representativa cuja admissão foi assim justificada pelo Ministro Relator: *"Tudo recomenda seja ouvido o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular Pessoal. Defiro a intervenção considerada a qualidade de terceiro, recebendo o requerente o processo no estágio em que se encontra"* (DJe 18/02/2006).

1.3. Na presente arguição, o setor de telecomunicações uma vez mais vindica justiça tributária em favor dos contribuintes representados, agora, pela **ACEL**, entidade que tem contribuído na construção da jurisprudência constitucional das telecomunicações.

1.4. São exemplos de ações no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade **ajuizadas pela ACEL** e **conhecidas pela Corte**: ADI´s 4715[5] (Rel. Min. Marco Aurélio), 5569 (Rel. Min. Rosa Weber, DJe 01/06/2017), 5585 (Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/08/2018), 5356 (red. p/acórdão Min. Marco Aurélio), 3835 (Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 02/08/2017), 5832 (Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29/10/2018), 6110 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/12/2021), 6087 (Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23/09/2019), 5585 (Rel.

[4] "Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional."
[5] ADI nº 4715, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19/08/2013.

Min. Edson Fachin, DJe 13/08/2018), 5569 (Rel. Min. Rosa Weber, 01/06/2017), 5574 (Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/10/2019) e 5608 (Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/10/2020).

1.5. Eis trecho do voto do ministro Gilmar Mendes, na **ADI nº 3846**, da **ACEL**:

> "Preliminarmente, reconheço a legitimidade da requerente para a propositura desta ação. Da leitura do estatuto social da empresa, verifica-se que constitui associação de abrangência nacional, representativa das empresas privadas prestadoras do Serviço Móvel Celular (SMC), constando, entre suas associadas, sociedades prestadoras de serviço em todo o território brasileiro. A caracterização da pertinência temática entre a atividade da requerente e o objeto desta ação, é verificada a partir do disposto no artigo 3º do estatuto social da ACEL (fls. 37, que dispõe, *ipsis litteris)*[6]: (...)". (grifado)

1.6. Fundada em 1998, a ACEL é associação de âmbito nacional que representa as operadoras de telefonia móvel. O art. 1º do Estatuto Social diz que congrega as prestadoras do Serviço Móvel Pessoal (SMP) autorizadas pela ANATEL para a exploração dos serviços de telefonia e de internet móvel. Tem, pois, homogeneidade. De acordo com o Anexo I do Estatuto, todas as empresas de telefonia móvel existentes no país integram a entidade. O art. 3º prova a pertinência temática. Eis a sua redação:

> "Art. 3º. A ACEL tem como objeto:
> (...)
> III. A representação dos interesses coletivos de suas Associadas perante instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário – da União, dos Estados e dos Municípios – e outras entidades de qualquer forma relacionadas com os objetivos sociais e com os interesses comuns das Associadas, dependendo de prévia autorização da Diretoria Executiva;
> IV. A divulgação e promoção, por meio da realização de simpósios, cursos e seminários, de atividades relacionadas ao mercado de telecomunicação móvel e outros afins, sempre voltados para a melhor capacitação se suas Associadas e demais interessados;
> V. A promoção, o incentivo e o custeio de estudos e ações que propiciem o desenvolvimento das telecomunicações no Brasil – em especial o do Serviço Móvel Pessoal

[6] ADI nº 3846, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/03/2011.

> –, a defesa da livre concorrência, dos princípios da ordem econômica no setor e a prática dos princípios regulamentares estabelecidos para a prestação do serviço;
> VI. O acompanhamento dos parâmetros estabelecidos pelos órgãos regulatórios, bem como a elaboração de prospecção de novos serviços e avanços tecnológicos que afetem as Associadas, por meio de monitoramento das tendências e mudanças no cenário nacional;
> VII. A integração com associações de classe que tenham como objetivo o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das atividades de telecomunicações."

1.7. Considerando, assim, o cumprimento de todos os requisitos de admissibilidade reclamados por essa Suprema Corte para o ajuizamento da presente ação por parte da ACEL, requer-se o reconhecimento da sua *legitimidade ativa ad causam*.

2. Dos Fatos: a necessidade de reafirmação do princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, novamente infringido pelos estados

2.1. Os comandos constitucionais revelam promessas ou determinações? Despertam a força normativa sobre a qual tratava Konrad Hesse[7] ou são apenas ilusões retóricas? Noutras palavras, a Constituição de 1988 é uma utopia ou uma realidade? O caso presente demonstrará a valia de se tentar encontrar respostas jurisdicionais a esses questionamentos.

2.2. Esta Ação impugna a produção de efeitos imediata de decretos publicados por estados federados que restabeleceram as alíquotas de ICMS sobre serviços de comunicação para os patamares vigentes antes da edição da Lei Complementar nº 194/2022[8], **sem observância do princípio da anterioridade nonagesimal**. No Mato Grosso do Sul, esse ato foi a publicação do Decreto nº 16.073/2022, que impôs uma alíquota de 27% aos serviços de comunicação; na Bahia, o Decreto nº 21.796/2022, que estabeleceu que esse mesmo item seria tributado a 26%. Ambos projetam os efeitos desse agravamento de ônus tributário para apenas poucos dias a frente, em direta infração à antecedência constitucionalmente prevista.

2.3. Desde há muito, diante da insistência das Fazendas Públicas estaduais em não conferirem autoridade à Constituição Federal, têm havido litígios entre as pessoas jurídicas

---

[7] A Força Normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: safE, 1991.
[8] Altera o CTN, e a LC nº 87/96 (Lei Kandir), para considerar bens e serviços essenciais os relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo, e as LCs nºs 192/2022, e 159/2017.

que prestam o serviço público essencial de telecomunicações – fortemente regulado, de espectro universal e demandante de extraordinários investimentos em infraestrutura – e os estados federados, cujo objeto é a aplicação do princípio da seletividade do ICMS. É que, em praticamente todo o país, embora o serviço de telecomunicação seja essencial para as pessoas de todas as classes sociais, as alíquotas do Imposto são muito mais elevadas que o percentual ordinário, situação que contraria o art. 155, § 2º, III da Constituição Federal (*princípio da seletividade* para o ICMS).[9] Atribui-se um tratamento mais gravoso a um serviço essencial, elevando a regressividade do sistema tributário e punindo os mais pobres.

2.4. Não sem razão, este STF, em 2021, julgou o RE nº 714.139, tendo fixado a seguinte tese para o Tema nº 745: *"Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços"*. Modulando-se os efeitos, a inconstitucionalidade da imposição de alíquotas de ICMS mais elevadas para os serviços de comunicação foi projetada apenas para 2024.

2.5. O Congresso, em seguida, editou a LC nº 194/2022, que adicionou o art. 18-A ao CTN [10], proibindo a tributação mais gravosa pelo ICMS de diversos setores econômicos, dentre os quais o de comunicações. Modificou ainda a LC nº 87/96 – Lei Kandir –, adicionando o seu art. 32-A, de conteúdo similar. Os artigos 9º e 15 da LC nº 194/2022, ademais, tornaram inequívoca a intenção do legislador de produção imediata de seus efeitos.

2.6. Com a superveniência dessa legislação, parlamentos locais e autoridades executivas dos mais diversos Estados se adequaram aos novos parâmetros derivados diretamente da própria realização da Constituição. No Mato Grosso do Sul, editou-se o Decreto Estadual

---

[9] "Art. 155. Compete aos Estados e ao DF instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...) § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...) III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;".

[10] "Art. 18-A. Para fins da incidência do imposto de que trata o inciso II do ***caput*** do art. 155 da Constituição Federal, os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo: I - é vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no **caput** deste artigo em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços; II - é facultada ao ente federativo competente a aplicação de alíquotas reduzidas em relação aos bens referidos no **caput** deste artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral; e III - é vedada a fixação de alíquotas reduzidas de que trata o inciso II deste parágrafo, para os combustíveis, a energia elétrica e o gás natural, em percentual superior ao da alíquota vigente por ocasião da publicação deste artigo."

nº 15.990/2022[11], que reduzia a alíquota para os 17% comuns aos demais bens e serviços, enquanto, na Bahia, foi instituído o Decreto nº 21.494/2022, que por sua vez reduziu a alíquota modal para 18%. Desde o último mês de julho, então, os contribuintes brasileiros vinham suportando níveis bem mais razoáveis de tributação sobre o consumo de serviços de comunicação, tornando-a mais consentânea com a capacidade contributiva e a seletividade.

2.7. O STF invalidou normas do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Norte e do Espírito Santo que fixavam a alíquota do ICMS para telecomunicações em patamar superior ao das operações em geral (ADIs 7109, 7121 e 7125). Julgou 21 das 25 ações ajuizadas pela Procuradoria da República: ADI 7123 (DF), ADI 7117 (SC), ADI 7111 (PA), ADI 7113 (TO), ADI 7116 (MG), ADI 7119 (RO), ADI 7122 (GO), ADI 7110 (PR), ADI 7126 (AP), ADI 7129 (AM), ADI 7118 (RR), ADI 7120 (SE), ADI 7108 (PE), ADI 7127 (PI), ADI 7131 (AC), ADI 7112 (SP), ADI 7128 (BA) e ADI 7130 (AL). Tudo parecia se encaminhar para que a jurisdição constitucional fosse respeitada até que, após a deliberação de algumas dessas ações, os Estados passaram a invocar a modulação operada nos referidos julgamentos para descumprirem a legislação complementar nacional a qual já vinham atendendo.

2.8. Mais grave que isso é que, nos decretos em questão, a previsão de majoração do ICMS é imediata, para janeiro de 2023, sem menção à observância do princípio da anterioridade nonagesimal, causando, por isso, uma nova controvérsia constitucional relevante. Os entes federados, além de invocarem a modulação para não se sujeitarem aos efeitos da Lei Complementar, agem como se ela nunca tivesse produzido efeitos, retomando a tributação anterior sem respeitar qualquer período de anterioridade.

2.9. Situações como a relatada nessa inicial demonstram que o ICMS é o último enclave estatal contra os efeitos da Constituição quanto às limitações do poder de tributar. É nele que tem se concentrado toda sorte de violações aos contribuintes.

---

[11] "Art. 1º A aplicação das normas de incidência do ICMS sobre as operações com os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo fica limitada nos termos do disposto neste Decreto. Art. 2º As autoridades administrativas deverão observar, na aplicação das normas de que trata o art. 1º deste Decreto, a alíquota máxima estabelecida no art. 18-A do CTN (Lei nº 5.172/66) e no art. 32-A da Lei Kandir (LC nº 87/96), com redação dada pela LC nº 194, de 2022. Parágrafo único. Considera-se como alíquota padrão, para efeitos da limitação estabelecida no caput deste artigo, o percentual de 17%." Art. 3º Este Decreto produzirá efeitos a partir de 1º/07/2022 e enquanto perdurar a eficácia das disposições da LC nº 194/2022."

2.10. Governadores já foram ao STF pedir para que a Suprema Corte reputasse os dados de programas de computador como uma mercadoria, para que, assim, pudessem tributá-los pelo ICMS.[12] Também já pediram, como se viu, a manutenção de alíquotas máximas de ICMS para os serviços de telecomunicação, equiparando-os a aviões, lanchas ou bolas de golfe.[13] Recentemente, requereram que o STF definisse ser possível se criar uma nova imposição tributária e cobrá-la no mesmo ano de criação (o caso DIFAL II).[14]

2.11. Agora, usam a modulação do STF sobre suas próprias decisões para inutilizar a legislação complementar e, sobretudo, o seu próprio comportamento anterior de reduzir o ICMS para se conformar a tal legislação. Os contribuintes invocam a anterioridade.

3. Do Cabimento: pertinência objetiva e regularidade formal

3.1. O art. 1º, parágrafo único, I, da Lei nº 9.882/99, delimita os objetos da ADPF:

> "Art. 1º A argüição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.
> Parágrafo único. Caberá também argüição de descumprimento de preceito fundamental:
> I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição"

3.2. No caso presente, tanto há atos do Poder Público sendo impugnados, quanto preceitos fundamentais da Constituição prejudicados. Ainda que fosse necessária a configuração do requisito da controvérsia, mais afeito à modalidade incidental, pode-se considerar bastante relevante a disputa constitucional ora posta.[15]

---

[12] ADIs 5576, 1945 e 5659.
[13] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue. 16 May 2011. Disponível em: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf>.
[14] ADIs 7066, 7070 e 7078.
[15] O ministro Luís Roberto Barroso, em obra doutrinária, define a relevância da controvérsia: "Será relevante a controvérsia quando o seu deslinde tiver uma repercussão geral, que transcenda o interesse das partes do litígio, seja pela existência de um número expressivo de processos análogos, seja pela gravidade ou fundamentalidade da tese em discussão, por seu alcance político, econômico, social ou ético. Por vezes, a reparação imediata de uma injustiça individual terá uma valia simbólica decisiva para impedir novas violações. Seja como for, na arguição incidental, mesmo que estejam em jogo direitos subjetivos, haverá de estar envolvida uma situação que afete o ordenamento constitucional de maneira objetiva." ***O controle de constitucionalidade no direito***

3.3. Ora, economicamente, trata-se da tributação, ainda que por alguns meses, de um dos serviços mais consumidos em um gigante continental como é o Brasil, com volume extraordinariamente relevante de recursos sob disputa. Juridicamente, define-se competências federativas e a autoridade das consequências da modulação ordenada por esta Corte, especialmente para a atividade legislativa, além dos efeitos do comportamento dos próprios entes federados. Estabelece-se, nesse sentido, os limites da hipótese de incidência do art. 150, III, "c" da Constituição, e a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal aos atos de "remajoração" do tributo.

3.4. Em relação aos atos do Poder Público questionados, são todos aqueles que, a revelia da LC nº 194/2022, e, principalmente, do princípio da anterioridade, promovem elevação imediata das alíquotas de ICMS dos serviços de comunicação em patamares superiores ao das operações em geral: Decreto nº 16.073/2022, do Mato Grosso do Sul; e Decreto nº 21.796/2022 da Bahia. Em ambos os decretos que compõem essa lista não exaustiva, inexiste previsão de observância da anterioridade nonagesimal para aplicar as alíquotas de 27%, pelo Mato Grosso do Sul, e 26% pela Bahia.

3.5. É importante notar que – em feito relacionado a este, a ADPF nº 984/DF – o Presidente da República já propôs esse tipo de ação contra atos do poder público de Estados diversos entre si, com espécies normativas diferentes. Naqueles autos, foi impugnada a não observância do princípio da seletividade do ICMS por leis ordinárias e leis complementares das 27 unidades da Federação. Esta Suprema Corte, prestigiando a eficiência da jurisdição constitucional, aceitou dirimir a controvérsia constitucional – posteriormente abarcada por um acordo – de forma concentrada naquele procedimento, evitando a multiplicação de ações do tipo. A ADPF cumpre melhor suas funções de defesa dos preceitos constitucionais e de solução de controvérsias relevantes dessa forma.

3.6. Vale repetir que o preceito fundamental guarnecido é o princípio da anterioridade nonagesimal - art. 150, III, "c" da Constituição. Pretende-se, então, que a controvérsia constitucional posta seja solucionada tendo como resultado a suspensão de eficácia dos atos normativos contrários à ordem constitucional.

---

brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2019. *E-book*. ISBN 9788553611959. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553611959/.

3.7. Em relação à exigência de subsidiariedade, prevista no art. 4º, § 1º da Lei nº 9.882/99, não há outro meio processual de impugnar decretos estaduais distintos entre si, embora com um único efeito (majoração imediata de ICMS), e um mesmo fundamento jurídico. Recomenda-se a utilização da ADPF, notadamente, por se tratarem de decretos estaduais.

3.8. Impor a utilização de meio alternativo, nesse contexto, reduziria severamente a eficácia dos conhecidos efeitos uniformizadores do controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que seria necessário litigar em vários procedimentos distintos, cada um praticado por um ente federado, gerando, por haver decisões judiciais dissonantes, uma imediata constituição de espécies de benefícios fiscais a dadas empresas de telefonia, a depender do Estado onde operem, algo profundamente deletério para o próprio usuário do serviço de telecomunicação, a quem cabe, em primeira hipótese, proteger. E, ainda mais, geraria disfuncionalidades sistêmicas num setor marcado pela necessidade regulatória de universalidade das características da sua prestação de serviços. **O conhecimento da presente ADPF milita em favor da própria autoridade da jurisdição constitucional.**

3.9. Ademais, presentes também os requisitos de regularidade formal. Nos termos do art. 3º da Lei nº 9.882/99[16], esta Petição indica os seus pedidos, com as devidas especificações, assim como os respectivos preceitos fundamentais violados. Instruída está com os documentos mencionados pela mesma lei, quais sejam, procuração *ad judicia* específica, cópia dos atos normativos impugnados, dentre alguns outros. A tempestividade é requisito formal inaplicável a esta espécie de ação, porquanto não há prazo definido na Constituição ou na lei própria (Lei Federal nº 9.882/99) para o exercício desta faculdade processual.

3.10. Por fim, também estão atendidas as exigências gerais para o conhecimento de qualquer ação, segundo o regime do CPC, em seu art. 319, como a indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos da demanda e o adequado endereçamento.

---

[16] "Art. 3º A petição inicial deverá conter: I - a indicação do preceito fundamental que se considera violado; II - a indicação do ato questionado; III - a prova da violação do preceito fundamental; IV - o pedido, com suas especificações; V - se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de mandato, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação."

4. Do princípio da anterioridade nonagesimal: necessidade de observância

4.1. Esta ação vindica o respeito, pelos Estados, quando do exercício de sua missão arrecadatória, do princípio da anterioridade tributária. É um reclame ligado às conquistas do constitucionalismo moderno, notadamente quanto aos direitos fundamentais.

4.2. O primado da segurança jurídica, abrangente da anterioridade, esta, cláusula da não surpresa, dimana da ideia de Estado Democrático de Direito.[17] A Constituição de 1988 abraça esse ideal. O seu art. 1º nos qualifica como sendo a República Federativa, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em "Estado Democrático de Direito".

4.3. O Preâmbulo não deixa de afirmar que esse Estado Democrático se destina, dentre outras missões, a assegurar a "segurança", esta que encontra morada tanto no *caput* do art. 5º (*Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos*) como no do art. 6º (*Dos Direitos Sociais*), a revelar sua máxima centralidade na topografia da Constituição de 1988, desdobrada, posteriormente, nas múltiplas cláusulas dedicadas ao Sistema de Justiça (*Capítulo III – Do Poder Judiciário*).

4.4. Nos três campos da vida em que são possíveis e justificadas restrições aos mais fundamentais direitos – ***liberdade, cidadania e propriedade*** –, a Constituição apresenta uma barreira intransponível, o princípio da anterioridade, qualificado, pelo art. 60, §4º, como cláusula pétrea.[18] Trata-se do núcleo protetivo contra até mesmo o Poder Constituinte Derivado Reformador, qual seja, o Congresso Nacional, no exercício do poder que lhe foi conferido pelo art. 60 da Constituição, que é o de aprovar emendas constitucionais.

4.5. Firme nesse compromisso, a Constituição traz o inciso XXXIX do art. 5º, a dizer: "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal". Então,

---

[17] Carta Magna de 1215: "Art. 12 – Não lançaremos taxas ou tributos sem o consentimento do Conselho Geral do Reino (*commue concilium regni*), a não ser para resgate de nossa pessoa, para armar cavaleiro o nosso filho mais velho e para celebrar, mas uma única vez, o casamento de nossa filha mais velha; e esses tributos não excederão limites razoáveis. De igual maneira se procederá quanto aos impostos da cidade de Londres." "Art. 29 – Nenhuma pessoa ou população poderá ser compelida, por meio de embargo de seus bens móveis, a construir pontes sobre os rios, **a não ser que seja contraída previamente esta obrigação**."

[18] Constituição Federal: "Art. 60. § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: (...) IV - os direitos e garantias individuais."

o art. 16: "a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência".[19]

4.6. Por fim, traz o art. 150, III, "b" e "c", dispondo que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos Municípios cobrar tributos: "b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou"; e "c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;".

4.7. A condição essencial para qualquer que seja a restrição da liberdade de ir, vir e permanecer; da cidadania eleitoral ativa (votar) e passiva (ser votado); e do imaculado direito de propriedade, cuja restrição vem com a tributação, é o **respeito à anterioridade.**

4.8. Por isso, os efeitos dos atos normativos inconstitucionais aqui impugnados hão de ser projetados para 90 dias no futuro, sob pena de gerar-se insegurança jurídica. Sobretudo, a exigência imediata da alíquota restabelecida – o que constitui majoração em relação ao patamar previamente vigente – implica em infringência direta do art. 150, III, "c":

> "Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
> (...)
> III - cobrar tributos:
> (...)
> c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;"

4.9. Ou seja, ocorrendo o fenômeno "*aumentar tributo*", é proibido cobrá-lo no patamar majorado antes de decorrida a noventena. Não se trata, na hipótese, de mera restauração de alíquota, e não majoração, pois a alíquota vigente, desde julho, em ambos esses Estados, era a alíquota-padrão, aplicável às operações em geral. A alteração normativa promovida pelos

[19] RE nº 633.703, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, Tema 387, DJ 18/11/2011: "(...) A proteção das minorias parlamentares exige reflexão acerca do papel da Jurisdição Constitucional nessa tarefa. A Jurisdição Constitucional cumpre a sua função quando aplica rigorosamente, sem subterfúgios calcados em considerações subjetivas de moralidade, o princípio da anterioridade eleitoral previsto no art. 16 da CF, pois essa norma constitui uma garantia da minoria, portanto, uma barreira contra a atuação sempre ameaçadora da maioria."

decretos, portanto, foi de cessar a incidência de uma alíquota inferior, antes vigente, e tornar exigível uma alíquota mais gravosa. Este é o conceito de majoração.

4.10. Nem se pode dizer que a teleologia do princípio está cumprida, porque não havia qualquer forma para que os contribuintes tivessem ciência de que ocorreria a restauração das alíquotas aplicadas desde julho de 2022. O comportamento dos entes federados foi de utilizar a modulação como pretexto para restaurar a tributação ofensiva ao princípio da seletividade.

4.11. Para esta Suprema Corte, qualquer elevação de ônus tributário, ainda que indireto, deve observar a restrição do princípio da anterioridade. Muito recentemente, no julgamento das ADIs nº 7.066; 7.070 e 7.078, o ministro Edson Fachin anotou o seguinte:

> "A despeito dos argumentos trazidos na tribuna virtual pelos Procuradores dos Estados de Alagoas e Ceará, nas ADIs n.7070 e 7078, não assiste razão aos mesmos, vez que **a Lei Complementar n.190/2022 ao dispor sobre a aplicação do DIFAL nas operações interestaduais praticadas com não-contribuintes veda, por exemplo, o amplo creditamento; o que indubitavelmente termina por corresponder a aumento do ônus tributário, logo, sujeita-se à observância de ambas regras da anterioridade (Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325 – DF**, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23- 09-2004, DJU 06-10-2006, p. 32.)." (grifos)

4.12. Na ADI nº 6.144/AM[20], sob a liderança do ministro Dias Toffoli, o Pleno consignou desde a ementa que "*Está sujeita às anterioridades geral e nonagesimal a majoração indireta do ICMS provocada pela instituição da substituição tributária em questão. Precedentes.*". No Voto-Condutor, cita-se ainda o precedente do RE nº 564.225/RS, da mesma relatoria, em que consta que "*Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos*". É mencionado, por fim, o julgado do ARE nº 1.281.713/RJ[21], de relatoria do ministro Edson Fachin.

---

[20] Trecho da ementa: "Ação direta julgada prejudicada quanto ao inciso II do art. 1º do Decreto nº 40.628/19, na parte em que fixou a Margem de Valor Agregado (MVA) de 150% em relação à energia elétrica, e procedente quanto à parte subsistente, declarando-se a inconstitucionalidade formal - por ofensa ao princípio da legalidade tributária - e material - por violação das anterioridades geral e nonagesimal - dos arts. 1º, I e II - na parte remanescente -, e 2º do mesmo decreto. 7. Ficam modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que a decisão produza efeitos a partir do início do próximo exercício financeiro (2022), ressalvando-se as ações ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito."

[21] Trechos da ementa: "1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele

4.13. Ainda que se permita a tributação excessiva a revelia da LC nº 194/2022 e em menoscabo ao próprio consumidor brasileiro, pelo menos a anterioridade, como garantia fundamental contra o poder de tributar, deve ser ostentada.

5. Dos Efeitos Perversos dos Atos Públicos Impugnados: necessidade de cognição das consequências constitucionais das elevações instantâneas de alíquotas

5.1. É importante considerar, por fim, os efeitos práticos, imediatos e nocivos dos atos do poder público ora impugnados. Embora essas consequências sejam muito mais do que se pode expor nesta oportunidade, importa mencionar apenas duas classes delas.

5.2. A primeira, ligada à insegurança jurídica, prejudica o equilíbrio econômico-financeiro da operação empresarial de telecomunicações em todo o País. Com efeito, tributos indiretos, incidentes sobre o consumo, são presumidamente repassados nos respectivos preços, como faz presumir o art. 166 do CTN, a Súmula nº 71/STF, a Súmula nº 546/STF e o precedente obrigatório da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 903.394/AL. Logo, desde julho, há de se presumir que os empreendimentos de comunicação têm praticado preços em acordo com o novo patamar de cobrança do ICMS. A mudança brusca – sem observância da anterioridade – obriga-as a suportar o prejuízo, até que possa repassar esse ônus adicional aos consumidores.

5.3. Por fim, ainda que se ignore os valores do Estado Fiscal que impõem evitar a tributação regressiva, de uma perspectiva puramente pragmática, também é importante recear os custos de transação decorrentes da pronta imposição dessas alíquotas contrárias à LC nº 194/2022. Com efeito, diversas normas administrativas, como a Resolução ANATEL nº 632/2014, em seu art. 52, e a Resolução ANATEL nº 426/2005, em seus artigos 47 e 48, impõem às sociedades empresárias do setor de comunicação determinada antecedência para comunicar ao consumidor a mudança de preços em sua fatura. No caso, a insegurança jurídica que se gerou com a redução de alíquotas em julho, e, agora, com a alteração ou

---

no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação".

restauração delas de surpresa e sem observância da anterioridade, impede que se cumpra essa antecedência exigida pela regulação setorial.

5.4. Obviamente, esse contexto tende a causar a imposição de multas, a instalação de litígios administrativos e judiciais, o provisionamento de verbas cuja obrigatoriedade de repasse é incerta, dentre outros. Se a própria elevação do ônus tributário tende a gerar ineficiência alocativa, pois é, por si, um custo de transação, esse agravamento, feito na forma atual, tende a gerar custos de conformidade em uma proporção extraordinária.

5.5. Princípios, enquanto mandados de otimização[22], exigem adequação de determinados meios aos fins cuja realização é prescrita. Esse juízo de adequação exige uma avaliação pragmática de se os meios produzem as consequências desejadas.

5.6. Nesta oportunidade, pretende-se que esta Suprema Corte, tendo em vista as consequências dos atos impugnados para vários princípios constitucionais – como a segurança jurídica, a capacidade contributiva, a livre iniciativa, dentre outros –, reconheça que esses efeitos, por si, constituem infrações à Constituição.

6. Dos Pedidos: concessão de tutela provisória de urgência

6.1. Diante do exposto, requer-se:

a) os imediatos recebimento e processamento da Petição Inicial e seus anexos;

b) a concessão de tutela provisória de urgência cautelar, determinando que todos os decretos impugnados – o Decreto nº 16.073/2022, do Mato Grosso do Sul, e o Decreto nº 21.796/2022 da Bahia – tenham seus efeitos suspensos, *ex tunc*, até que completem o prazo de 90 dias de sua publicação, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal;

c) a comunicação de todos os atos processuais ao advogado Marcelo Montalvão Machado, já devidamente qualificado, sob pena de nulidade;

---

[22] Silva, Virgílio Afonso da. ***Direitos Fundamentais: Conteúdo Essencial, Restrições e Eficácia***. 2ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2014.

d) a intimação do Advogado-Geral da União, para manifestar-se sobre esta Ação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 103, § 3º da Constituição Federal;

e) a intimação do Procurador-Geral da República, para proferir parecer também no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 103, § 1º da mesma Constituição; e

f) como tutela definitiva, a declaração de aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal aos atos normativos ora impugnados que majoram, acima do patamar das operações em geral, o ICMS incidente sobre os serviços de comunicação.

6.2. Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para fins meramente fiscais.

E. deferimento.

Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023.

Saul Tourinho Leal
OAB/DF 22.941

Marcelo Montalvão Machado
OAB/DF 34.391

Cairo Trevia Chagas
OAB/CE 36.180 | OAB/DF 63.857

ASSINADO DIGITALMENTE
DESYREE TAVARES RAMOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO